

<제05장 취소소송의 심리.제03절 처분사유의 추가·변경>

[기출][2015-1-2]개발행위 불허가 처분 취소소송 중 기반시설 설치계획 부적절 사유 외 환경 부조화 사유 추가 가능 여부

《【문제1】 甲은 2015. 1. 16. 주택신축을 위하여 개발행위허가를 신청하였다. 이에 관할 행정청 乙은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 의거하여 `해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절하지 않다`라는 사유로 2015. 1. 22. 개발행위 불허가 처분을 하였

고, 그 다음날 甲은 그 사실을 알게 되었다.

그런데 乙은 위 불허가 처분을 하면서 甲에게 그 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구기간을 알리지 아니하였다. 甲은 개발행위 불허가 처분에 불복하여 2015. 5. 7. 행정심판위원회에 취소심판을 청구하였다. 아울러 甲은 적법한 제소요건을 갖추어 취소소송도 제기하였다. (50점)

(물음2) 乙은 취소소송의 계속 중 `국토 및 자연의 유지와 환경보전 등 중대한 공익상의 필요가 있고 주변 환경이나 경관과 조화를 이루지 못 한다`라는 처분사유를 새로이 추가할 수 있는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 개발행위 불허가 처분 취소소송 중 기반시설 설치계획 부적절 사유 외 환경 부조화 사유 추가 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 개발행위 불허가처분의 취소를 구하는 소송 계속 중 처분청 乙은 당초의 기반시설 확보계획 부적절이라는 처분사유 외에 국토 및 자연의 유지와 환경보전 등 중대한 공익상의 필요와 주변 환경·경관과의 부조화라는 새로운 처분사유를 추가하려고 한다. 쟁점으로 <취소소송 계속 중 당초 처분사유와 다른 새로운 처분사유를 추가하는 것이 처분사유의 추가·변경으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 취소소송의 계속 중 새로운 처분사유를 추가할 수 있는지 설명한다.

II. 처분사유의 추가·변경의 법리

1. 처분사유의 추가·변경의 의의 및 필요성

(1) 개념 및 성격

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 소송 계속 중에 처분의 적법성을 유지하기 위해 처분 당시 제시했던 사유 외에 다른 사유를 추가하거나 변경하여 주장하는 소송법상 행위를 말한다.

(2) 인정의 필요성

- 행정소송법상 명문 규정은 없으나 법원은 분쟁의 일회적 해결을 통한 소송경제 도모와 반복 소송의 방지를 위해 제한적인 범위 내에서 처분사유의 추가·변경을 인정하고 있다.

2. 처분사유의 추가·변경의 허용 한계

(1) 기본적 사실관계의 동일성 요건

- 추가되는 사유는 당초 처분사유와 기본적 사실관계에서 동일성이 유지되어야 한다. 동일성 여부는 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 침해 법익 등을 종합하여 사회적 사실관계가 객관적으로 동일한지에 따라 판단한다.

(2) 시간적 및 절차적 요건

- 처분사유의 추가·변경은 처분 당시에 이미 존재했던 객관적 사실에 한하여 허용되며(시간적 한계), 원고의 실질적 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 허용되어야 한다(절차적 한계).

III. 사안의 적용

1. 당초 처분사유와 추가 처분사유의 사실관계 비교

(1) 당초 처분사유의 성격

- 당초의 사유인 `기반시설의 설치 및 용지확보계획 부적절`은 개발행위 자체의 기술적·물리적 계획상의 미비점을 지적한 것이다.

(2) 추가 처분사유의 성격

- 추가하려는 사유인 `국토 및 자연의 유지, 환경보전 등 공익적 필요 및 경관과의 부조화`는 개발행위가 주변 환경에 미치는 생태적·공익적 영향을 판단한 것이다.

2. 기본적 사실관계의 동일성 여부 판단

(1) 구체적 판단 및 판례의 태도

- “대법원 판례”에 의할 때, 개발행위허가신청 거부처분의 당초 사유인 `기반시설 설치나 그에 필요한 용지확보계획 부적절`과 소송 과정에서 추가하려는 사유인 `인근 토지의 환경·경관 저해 및 환경보전 등 공익상 필요`는 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 객관적으로 동일하다고 보기 어렵다.

(2) 피고 乙의 주장에 대한 법원의 조치

- 두 사유 사이에는 기본적 사실관계의 동일성이 부정되므로, 법원은 피고 乙의 처분사유 추가 주장을 허용해서는 안 된다.

IV. 결론

- 취소소송 중 피고 행정청의 처분사유의 추가·변경 주장은 당초의 사유와 추가하려는 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 존재해야만 허용된다. 사안에서 乙이 추가로 주장하는 환경보전 및 경관조화의 사유는 당초 사유인 기반시설 및 용지확보계획 부적절과 객관적 사실 내용이 완전히 다른 별개의 사유에 해당한다. 따라서 양 사유 간에는 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않으므로, 법원은 피고 乙의 추가 주장을 허용해서는 안 되며 당초의 기반시설 관련 사유만을 기준으로 불허가처분의 적법 여부를 심리하여야 한다.